刑法09 筆記：上級命令與醫療行為

> 來源：刑法09 課程字幕 02:26:00 ~ 02:38:23

🕮 法條原文速查

> **§21 II**（上級命令之行為）
> 依所屬上級公務員命令之行為，不罰。但明知命令違法者，不在此限。

> **§22**（業務上正當行為）
> 業務上之正當行為，不罰。

釋字／實務見解速查

> 實務見解：§21 II「明知命令違法」→ 不分形式或實質合法性，只要明知違法即不能阻卻違法。

一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§21 II 上級命令四要件？」	①具有拘束力之命令（事務範圍內）②命令具備法定程序③不逾越授權範圍④不能明知違法
「明知命令違法，何種合法性？」	**學說**：僅限形式合法性 vs **實務**：形式＋實質都算
「業務上正當行為採何說？」	**事實業務說**：重點是行為正當，非業務正當
「密醫拔牙，可否阻卻違法？」	**可以**（事實業務說→行為符合醫療常規→正當→阻卻違法；無照行醫另論）
「醫療行為是否該當傷害罪？」	**傷害說**：該當→阻卻違法 vs **非傷害說**：根本不該當傷害
「非傷害說之要件？」	①醫療目的②告知後同意③符合醫療常規④緩解疼痛疾病
「專斷醫療可否阻卻違法？」	**原則不行**（違反病患意思→欠缺同意基礎）

一、§21 II 上級命令

四要件

```
上級命令阻卻違法 §21 II
│
├── ① 具有拘束力的命令
│     └── 上下級公務員的事務範圍之內
│     └── ✗ 上級叫下級跟蹤他老婆 → 超出事務範圍 → 不適用
│
├── ② 命令具備法定程序
│     └── 書面等形式要件均須符合
│
├── ③ 不逾越授權範圍
│     └── 超越原本授權 → 不能阻卻違法
│
└── ④ 不能明知命令違法
      └── 爭議：何種「合法性」？
```

明知命令違法之爭議

立場	內容	理由
學說	僅限知悉**形式合法性**違反	不能要求下級審查上級命令之實質合法性（違反行政倫理）
實務	形式＋實質**都算**	只要明知命令違法，不分形式或實質，均不能阻卻違法

二、業務上正當行為（§22）

事實業務說

```
§22 業務上之「正當行為」
        ↓
重點：「行為」正當 ≠ 「業務」正當
        ↓
業務不合法（如密醫）→ 只要行為本身正當 → 仍可阻卻違法
```

「行為正當」之最低限度

- 行為本身**不能抵觸其他法領域**

案例	行為正當？	理由
密醫（齒模師）幫病患拔牙	☑	拔牙行為符合醫療常規，沒有法律禁止「拔牙行為本身」；無照行醫另依其他法律處理
警察刑求被告	✗	刑事訴訟法**禁止**刑求 → 行為抵觸其他法領域 → 不正當

真正只能用業務正當行為的情況

- 其實**不多**，很多情況可走其他阻卻違法事由替代
- 公務員執法 → 可走§21
- 醫療行為 → 可走被害人同意、緊急避難
- **記者臥底採訪** → 唯一只能用業務上正當行為的典型案例
    - 例：記者喬裝成工廠員工臥底，用密錄器拍下黑心食品工廠運作
    - 找不到其他阻卻違法事由 → 只能用§22

三、被害人同意與專斷醫療

醫療行為需同意

情況	法律效果
患者/家屬**事前同意**	可阻卻違法（被害人承諾）
未取得事前同意	頂多主張**推測的承諾**（超法規阻卻違法事由）
違反病患意思（專斷醫療）	**原則不能阻卻違法**

> 不管怎麼樣，你要經過人家同意；對方有病不想醫，你不能強迫。

四、醫療行為論罪：傷害說 vs 非傷害說

比較

	傷害說（傳統說）	非傷害說（漸成主流）
構成要件該當	醫療行為**該當**傷害罪	醫療行為**不該當**傷害罪
不罰理由	有阻卻違法事由（業務正當/被害人承諾）	根本不符合傷害罪構成要件
觀察方式	聚焦一刀一針一線	看**整體**醫療行為
論理	拔牙 → 少一顆牙＋出血 → 傷害	原本不健康 → 治療後更健康 → 整體非傷害

非傷害說四要件

```
醫療行為不該當傷害（非傷害說）
│
├── ① 出於醫療目的
├── ② 告知後同意
├── ③ 符合醫療常規
└── ④ 以緩解疼痛、緩解疾病為目的
```

拔智齒案例分析

```
智齒長歪 → 壓迫臼齒 → 牙齦經常發炎
          ↓
     口腔處於「不健康」狀態
          ↓
     醫師拔除長歪智齒
          ↓
     少一顆牙＋過程出血
          ↓
  ┌──────────────────────────────┐
  │ 傷害說 → 該當傷害 → 阻卻違法      │
  │ 非傷害說 → 整體觀之更健康 → 不該當 │
  └──────────────────────────────┘
```

考試提醒

- 醫療刑法**通常考研究所**（王皇玉老師、曾淑偉老師）
- 國考偶爾出現（109年曾有一試考題涉及）
- 一試出題 → 記住兩說及非傷害說四要件即可

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§21 II	依上級命令之行為	四要件＋明知違法爭議
§22	業務上正當行為	事實業務說＋行為正當
§277	傷害罪	醫療行為是否該當？
§16	法律意識的欠缺	明知違法但以為可主張上級命令
醫療法/醫師法	醫療行為規範	無照行醫→另依醫師法處理
刑訴 §98	禁止刑求	警察刑求不能主張業務正當